

1500252-85.2021.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: SAMARA ELIZA LUTHERI FELTRIN NESPOLI

Comarca: Santo Anastácio

Foro: Foro de Santo Anastácio

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... (i) autos nº 0000004-43.2014.8.26.0585, tráfico de drogas; trânsito em julgado em 25/04/2016; extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em 11/11/2020; (ii) autos nº. 0000128-55.2016.8.26.0585, tráfico de drogas, trânsito em julgado em 25/08/2017, em cumprimento de pena.

A fim de evitar "bis in idem", a primeira condenação será valorada na segunda fase de aplicação da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo Anastácio

Foro de Santo Anastácio

Vara Única

Praça Ataliba Leonel, 251, Santo Anastacio-SP - cep 19360-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500252-85.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500252-85.2021.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDERLAN OLIVEIRA DE AMORIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SAMARA ELIZA FELTRIN

1. RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra EDERLAN OLIVEIRA DE AMORIM, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 14, "caput", da Lei nº. 10.826/03, porque:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 04 de dezembro de 2021, por volta das 20h23min, na Rua Paraná, nº 352, Vila Gonçalves, nesta cidade e comarca de Santo Anastácio, EDERLAN OLIVEIRA DE AMORIM, qualificado à fl. 04, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 01 Garrucha de dois canos, marca "Brezelien", calibre 38, de uso permitido, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 09 e laudo pericial de fls. 143/145.

Segundo se apurou, policiais militares receberam informações, via COPOM, de que o acusado portava arma de fogo. Deslocaram-se até o local dos fatos, oportunidade em que abordaram Ederlan e, em busca pessoal, encontraram, acondicionada em sua cintura, uma garrucha de dois canos, calibre 38, marca "Brezelien", sem numeração aparente e desmuniada. Em ato seguinte, as autoridades policiais deram voz de

prisão ao réu, que confessou o crime de porte de arma de fogo de uso permitido. Diante o recolhimento da fiança, arbitrada em R\$ 800,00, o acusado foi liberado. Submetido a exame pericial (fls. 143/145), constatou-se que referida arma de fogo estava apta a realizar disparos.

O feito teve início com a prisão em flagrante do autuado.

Arbitrada fiança pela autoridade policial, foi o acusado solto após comprovação de recolhimento (fls. 23 e 63).

Às fls. 37/38, manifestou-se o Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, diante dos antecedentes do réu.

O cárcere cautelar foi decretado por decisão de fls. 46/50, afastando-se a fiança outrora arbitrada.

Ofertado relatório final (fls. 85), a denúncia foi oferecida às fls. 89/90 e recebida por decisão de fls. 115/116, em 09 de dezembro de 2021.

O acusado foi citado e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 136/141).

Ausente hipótese de absolvição sumária (art. 397, CPP), foi determinado o prosseguimento do feito.

Em sede de audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do acusado.

Em seguida, as partes apresentaram seus memoriais, requerendo o Ministério Público a procedência da ação penal e a defesa a absolvição do acusado com esteio na atipicidade da conduta, aduzindo, ainda, teses subsidiárias (aplicação da atenuante da confissão).

Após, vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Não se vislumbram nulidades processuais ou questões preliminares a serem analisadas, tendo sido, ainda, observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, motivo pelo qual passo à análise do mérito.

Sem dúvida que a absolvição do acusado, à vista da prova existente nos autos, é positivamente descabida, pois os fatos referidos na denúncia foram ao longo da instrução devidamente comprovados.

A materialidade do fato está comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante de fl. 1; boletim de ocorrência de fls. 06/08; auto de exibição e apreensão de fl. 09 – indicando a apreensão de uma garrucha de dois canos, marca “Brezelien”, calibre .38, em bom estado de conservação; laudo de prestabilidade de fls. 143/145, indicando a aptidão do armamento para realizar disparos, e, indiretamente, pela prova oral amealhada aos autos.

Da mesma forma, a autoria é certa e recai sobre o acusado.

O policial José Rodrigues Sobral Filho contou que realizava patrulhamento, na companhia do colega de farda André Luiz Borges, quando foi informado, via COPOM, de que o réu estava em uma padaria, exibindo arma de fogo às pessoas que ali se encontravam. Em diligência, encontraram Ederlan na porta de um bar, em frente à praça, oportunidade em que o abordaram. Durante revista pessoal, foi encontrada, na cintura, uma arma de fogo tipo garrucha, dois canos, calibre 38, marca “Brezelien”, em bom estado de conservação, sem numeração aparente e desmuniada. Ao ser questionado, o denunciado informou não possuir documentação da arma, bem como que a utilizava para defesa pessoal. Em Juízo, ratificou as informações, frisando que a arma foi encontrada, durante revista pessoal, na cintura do acusado. Ao indagá-lo, o réu disse que arma era para defesa pessoal; que não possuía documentos; e que estava em cumprimento de livramento condicional, em razão de condenação pelo crime de tráfico de drogas.

No mesmo sentido, o depoimento de André Luiz Borges, policial militar, que acompanhou José Rodrigues durante a diligência.

Em seu interrogatório policial, o acusado afirmou que, no dia dos fatos, havia saído de casa para comprar cerveja em um bar, oportunidade em que foi abordado por

policiais militares. Em que pese não ter informado o motivo de estar armado, confirmou que portava, na cintura, uma arma de fogo – Tipo Garrucha - desmuniada. Sobre a origem, informou que a arma era de seu pai, mas que não possui a documentação dela. Em Juízo, confessou a acusação. Ratificou que, quando foi abordado, portava uma garrucha, dois canos, calibre 38, marca “Brezelien”, desmuniada; que não possui registro da arma, tampouco porte. Acrescentou que a arma pertencia ao seu pai, e que sua intenção era retirar o armamento de casa e escondê-lo em um terreno. Reconheceu a ilicitude de seu ato. Já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas.

Pois bem.

Como se vê, a prova oral não apresenta complexidade.

Da análise universal e cronológica da prova produzida nos autos, emerge a certeza quanto à autoria do fato pelo acusado.

Consigno que a valia do testemunho do policial pode ser questionada quando desmentida por outras provas, o que não ocorre no presente caso, em que sua declaração, ratificada em Juízo, converge para com os demais elementos trazidos ao feito.

Ademais, não há substrato probatório apto a demonstrar especial interesse do policial no julgamento do feito, dado inexistir comprovação de animosidade anterior entre ele e o acusado.

A respeito:

TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências que culminaram com a acusação da prática de crimes por parte do apelante devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. [...] (TJRS. 1a Câmara Criminal. Apelação Crime 70075792101. Relator: Sylvio Baptista Neto. Julgado em: 31/01/2018).

Assim, sopesadas a prova testemunhal e a situação de flagrância, não há falar em insuficiência probatória ou dúvida acerca da autoria delitiva, que recai, de modo evidente, sobre o acusado.

Sobre a adequação típica, necessário consignar, inicialmente, que o art. 14 da Lei n. 10.826/2003 pune a conduta daquele que porta, detém, adquire, fornece, recebe, tem em depósito, transporta, cede, ainda que gratuitamente, empresta, remete, emprega, mantém sob sua guarda ou oculta arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples fato de o agente praticar a conduta típica, sem necessidade de resultado naturalístico, tendo em vista tutelar a segurança coletiva, sendo desprovida a prova do perigo concreto a bem jurídico de terceiro.

Segundo lição de Gilberto Thums (Estatuto do Desarmamento. Rio de Janeiro: São Paulo: Lumen Juris, p. 30), “o Estatuto do Desarmamento tem por objeto de tutela a segurança pública, a incolumidade pública ou a segurança coletiva. Por se tratar de bem jurídico coletivo, transindividual, típico das modernas sociedades de risco, não pode prever condutas de lesão ou de perigo concreto. Toda vez que o agente realiza determinada conduta, presume-se que coloca em risco o bem jurídico”.

De igual forma, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARMA DESMUNIADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA.

TIPICIDADE. A jurisprudência recente desta Corte é pacífica no sentido de que, para a caracterização do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, por ser de perigo abstrato e de mera conduta, e colocar em risco a incolumidade pública, basta a prática dos núcleos “ter em posse” ou “portar”, sem a devida autorização legal (precedentes). Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no AREsp: 969191 SC 2016/0217822-6, Relator: Ministro Felix Fischer, data do julgamento 10.11.2016, T5

- Quinta Turma, data da publicação DJE 23.11.2016).

PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO CORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. DISPENSABILIDADE DE MUNIÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ – Resp: 1960425 MG 2021/0295839-0, Telator : Ministro Jesuino Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), data do julgamento 07.10.2021, data de publicação DJ 11.10.2021).

Dessa feita, não há falar em atipicidade por ausência de demonstração de perigo concreto na conduta do acusado, bastando, como já dito, a comprovação do porte do armamento, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, independentemente da presença de munição. Ademais, da análise do preceito primário incriminador, infere-se que o fato de o armamento pertencer ou não ao acusado não interfere na plena subsunção típica, dada a não exigência de propriedade do armamento, acessório ou munição. Em outras palavras, suficiente que o agente tenha praticado um dos verbos descritos no tipo objetivo – no caso, portar arma de fogo –, de modo que prescindível a comprovação da propriedade dos artefatos bélicos apreendidos em seu poder, bastando a manutenção da guarda do armamento, ainda que por curto período, fato provado nos autos. Do mesmo modo, não prospera a tese de não lesividade, dado que, conforme laudo pericial constante dos autos (fls. 143/145), a arma examinada apresentava condições normais de uso e funcionamento, caso em que também não se cogita de atipicidade da conduta.

Veja que, para que possa se falar em crime impossível, o laudo pericial deveria atestar a absoluta impropriedade do meio utilizado, no caso, a arma de fogo. Havendo, ao menos, relativa impropriedade, mantém-se a tipicidade, dado que o instrumento ainda era potencialmente apto a lesionar o bem jurídico.

Nessa linha:

“[...] Arma incapaz de disparar não pode ser considerada arma, nos termos da definição do Decreto 3.665/2000. E se não pode atingir o bem jurídico protegido, trata-se de crime impossível. Mas, lembremos, o art. 17 do CP exige ineficácia absoluta do meio, de modo que, mesmo havendo a necessidade de algum procedimento excepcional para a realização do disparo, mas desde que este seja possível, a ineficácia será apenas relativa e, assim sendo, haverá o crime. Da mesma forma, somente existirá o crime se a munição for apta a ser disparada, ou seja, se puder ser deflagrada”. (Rogério Sanches. Leis Penais Especiais Comentadas. Salvador, Editora Juspodivm, 2018 - págs. 1530/1531).

“[...] Consoante consignado em reiteradas decisões deste Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido de que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo e, assim, desnecessária a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida. No entanto [...], nos termos do que proferia o ilustre Ministro aposentado Nilson Naves, 'arma, para ser arma, há de ser eficaz; caso contrário, de arma não se cuida' (AgRg no HC 149.191/RS). Isso porque, uma arma desmuniada em conjunto com munição torna-se apta a realizar disparos; entretanto, uma arma ineficaz, danificada, quebrada, em contato com munição, não poderá produzir disparos, não passando, portanto, de um mero pedaço de metal. Logo, Demonstrada por laudo pericial a total ineficácia da arma de fogo e das munições apreendidas, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do agente que detinha a posse do referido artefato e das aludidas munições de uso proibido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal/regulamentar [...]”. (STJ. 6ª Turma. REsp 1.451.397-MG. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em: 15/09/2015. DJe: 01/10/2015).

Veja que o laudo pericial deixa claro que a arma de fogo apresentava eficácia na realização de disparos.

Logo, plena a subsunção do fato ao preceito incriminador do art. 14 do Estatuto do Desarmamento.

Por fim, irrelevante o fato narrado informalmente pelo acusado aos policiais, durante a diligência, no sentido de que utilizava a arma para defesa pessoal, dado que tal situação não caracteriza legítima defesa ou exercício legítimo de um direito. Havendo prova do porte do armamento, impõe-se a condenação.

Nas palavras do Tribunal Bandeirante:

“[...]”

Não vinga a pretensão atinente à excludente do estado de necessidade, calcada na alegação de que o armamento se destinava à defesa pessoal do apelante ou, até mesmo, de seus familiares. O pressuposto da descriminante ora invocada é a existência de um direito do agente ou de terceiros, que é salvo com o sacrifício do direito de outrem.

Logo, não se pode dizer amparado pela justificativa penal quem é surpreendido pela polícia na posse de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como mantendo sob sua guarda diversas munições, sob a vazia alegação de que assim agia para resguardar a sua própria vida.

O extinto Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo já se pronunciou no sentido de que “para o reconhecimento da excludente de estado de necessidade, que legitimaria a conduta do agente, é necessária a ocorrência de um perigo atual e não um perigo eventual e abstrato” (RJDTACRIM 11/135). Assim também é o posicionamento desta Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal (Apelação nº 993.06.010702-0, Rel. DES. HERMAN HERSCHANDER, j. 09.09.2010).

Do mesmo modo, não procede a alegada atipicidade da conduta, já que o apelante em nenhum momento comprovou qualquer registro ou documento que comprovasse a propriedade da arma e das munições. [...]”. (TJSP. 14ª Câmara de Direito Criminal. Apelação Criminal nº. 1500133-04.2019.8.26.0486. Relator: Fernando Torres Garcia. Julgado em: 10/08/2020. DJe: 10/08/2020).

De mais a mais, também não merece guarida a tese de ausência de dolo ou de erro de tipo, já que é presumido o conhecimento do ordenamento e das normas jurídicas, especialmente quando se trata de fato notoriamente delituoso. Qualquer homem médio tem condições de saber que o porte de armas, munições ou acessórios bélicos, sem autorização legal, configura crime.

Dessarte, caracterizada a existência do crime, provada sua autoria por parte do réu e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou de isenção de pena, a condenação é medida que se impõe, já que a conduta encontra correspondência com a narrativa fática contida na inicial, afastando-se as teses defensivas remanescentes.

De todo o exposto, conclui-se, de forma clara e isenta de qualquer dúvida, que o réu praticou o delito a ele imputado na incoativa, não existindo causas que excluam a antijuridicidade ou a culpabilidade, nada podendo afastar a tipicidade do delito praticado, sendo robusta e isenta de qualquer dúvida a prova.

Praticando um fato típico, antijurídico e culpável, reclama o acusado uma resposta penal proporcional à ofensa ao bem jurídico atingido, em caráter preventivo e repressivo, objetivando, também, sua reintegração social.

3. DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para CONDENAR EDERLAN OLIVEIRA DE AMORIM, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 14 da Lei nº. 10.826/03.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Passo a individualizar a pena, considerando as diretrizes traçadas pelo artigo 59

do Código Penal e dentro do estritamente necessário e suficiente à retribuição e prevenção da conduta delituosa praticada.

4.1. Da pena privativa de liberdade

I- Primeira fase de fixação

A culpabilidade (grau de reprovabilidade da conduta) não pode ser sopesada em seu desfavor, visto que normal para o tipo.

Possui antecedentes criminais (fls. 128/132): (i) autos nº 0000004-43.2014.8.26.0585, tráfico de drogas; trânsito em julgado em 25/04/2016; extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena em 11/11/2020; (ii) autos nº. 0000128-55.2016.8.26.0585, tráfico de drogas, trânsito em julgado em 25/08/2017, em cumprimento de pena.

A fim de evitar "bis in idem", a primeira condenação será valorada na segunda fase de aplicação da pena, como reincidência, enquanto a segunda será aqui aplicada.

A conduta social não está desabonada nos autos.

A personalidade da agente não apresenta traços dissonantes, aferíveis a partir de um juízo leigo.

Os motivos, circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo, de modo que não comportam desvalor.

Nada há a ser dito a respeito da moduladora "comportamento da vítima".

Deste modo, analisados os vetores acima delineados, tomando por base o intervalo entre as penas mínima e máxima, dividido por 7 circunstâncias judiciais (não incluído o comportamento da vítima, por não influenciar na subsunção típica), fixo a pena base em 2 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão.

II - Segunda fase de fixação

Presente a agravante da reincidência, na forma explanada na 1ª fase.

Presente a atenuante da confissão espontânea.

Compensadas, mantenho a pena intermediária em 2 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão.

III - Terceira fase de fixação

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena.

4.2. Da pena de multa

A sanção pecuniária é cumulativamente cominada à espécie delitiva.

Assim, diante da análise já realizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, guardada a devida proporção, fixo-a em 50 (cinquenta) dias-multa (art. 49, caput, do CP).

Em atenção à situação econômica do réu, sem notícia quanto aos seus efetivos rendimentos, estabeleço o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, atualizável quando da execução (arts. 60; 49, §§1º e 2º, do CP).

4.3. Pena definitiva

Assim, vai o acusado condenado a 2 anos, 3 meses e 14 dias de reclusão e ao pagamento de 50 dias-multa, na forma acima exposta, penas estas que torno definitivas, ante a ausência de outras causas modificadoras.

5. DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO

Não há detração a ser operada, nos termos do § 2º do art. 387 do CPP, pois o réu não permaneceu detido provisoriamente por este processo.

Considerando as circunstâncias judiciais, bem como o quantum de pena aplicado, atrelado à reincidência, deverá o réu cumprir a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, atendendo-se ao disposto no artigo 33, parágrafo 1o, alínea "c", e ao seu parágrafo 3º, que remete às circunstâncias judiciais do art. 59, todos do Código Penal, por considerar este regime suficiente como resposta penal.

6. ARTIGOS 44 E 77 DO CP

Considerando as circunstâncias judiciais que não foram integralmente favoráveis, e especialmente a reincidência, ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade fixada por restritiva de direitos, nem a suspensão condicional da pena.

7. DIREITO DE RECORRER

Considerando que o réu respondeu a todo o processo segregado e que, à luz das circunstâncias envoltas à prática do ilícito, persistem os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva e posterior manutenção, que dizem com a garantia da ordem pública (necessidade de prevenção à reiteração delitiva), aos quais me reporto, a fim de evitar desnecessária tautologia, deixo de conceder a ele o direito de recorrer em liberdade, bem como de substituir a segregação por medidas cautelares diversas.

8. INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA

Como não houve contraditório nos autos acerca da indenização mínima (art. 387, inc. IV, do CPP), não há como promover seu arbitramento, sob pena de violação a princípio constitucional.

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Condeno o acusado ao pagamento das despesas processuais (art. 804 do CPP).
2. Após o trânsito em julgado:
 - a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;
 - b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão de seus direitos políticos;
 - c) expeçam-se as demais comunicações pertinentes;
 - d) remetam-se os autos ao Contador, para elaboração da conta de custas e da pena de multa;
 - e) forme-se o PEC definitivo, remetendo-o à Vara de Execuções Criminais, arquivando-se estes autos oportunamente;
 - f) certifique-se quais dos objetos permanecem apreendidos nos autos e dê-se vista ao Ministério Público para que opine quanto a destinação.
 - g) declaro a fiança perdida, devendo ser utilizada nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal.

P.I.C.

Santo Anastacio, 15 de fevereiro de 2022.

Samara Eliza Feltrin
Juíza Substituta

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA